Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 15ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0032722-21.2021.8.17.2001**

AUTOR: P. M. M. D. M.

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos, etc…

PEDRO MIGUEL MOURA DE MIRANDA, menor impúbere, já qualificado, por meio de seu represente e devidamente representado pelo seu advogado legalmente constituído, propôs a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA**, em face da **UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (UNIMED RECIFE)**, alegando resumidamente que (Id. nº 80299452) que:

1. É segurado do Plano de Saúde com a Ré contratada, sendo portador da carteira de identificação nº 0 034 550100192710 4, no plano da rede de atendimento ES04 BÁSICO, estando em dia com as mensalidades.
2. Infelizmente, no final de novembro do ano de 2016 com 11 anos de idade, o autor adquiriu uma doença autoimune, e diante da internação, dos exames laboratoriais e complementares, o adolescente foi diagnosticado com DIABETES MELLITUS do tipo 1 (CID-10: E.10), não vindo mais à produzir INSULINA no corpo, elevando por consequência o nível de açúcar no sangue.
3. Posteriormente, aos 12 anos de idade, o Requerente também foi diagnóstico com hipopituitarismo, doença endócrina caracterizada pela diminuição da secreção de um ou mais dos oito hormônios normalmente produzidos pela glândula pituitária (hipófise), na base do cérebro. Que em seu caso decorre da deficiência de hormônio de crescimento, com índice abaixo do limite considerado normal para a sua idade e perfil familiar. Visando adequar sua estatura ao nível médio adequado, sua médica assistente Dra. Taciana Schuller, indicou o uso da substância SOMATROPINA com a dose diária injetável e continuada de 1 UI SC ao deitar.
4. Para tanto, é essencial realizar o autoexame através do aparelho glicosímetro, obtendo amostras de sangue capilar para testes sanguíneo. Ou seja, a medição do nível de açúcar no sangue é obtida através de furadas nos dedos para extrair uma gota de sangue e aplicar na fita reagente diversas vezes ao longo do dia.
5.Conforme o laudo médico, demonstra que o menor faz uso de insulinas (LANTUS/DEGLUDECA e NOVORAPID/HUMALOG) de acordo com a contagem de carboidrato, sendo que para o referido método, necessita do acompanhamento diário da glicemia que o obriga a se submeter entre a 6 (seis) e oito (oito) glicemias capilares em apenas um dia. Tal procedimento no glicosímetro, exige do adolescente repetitivas furadas no dedo, que somam há ao mês são 240 a 300 vezes e ao ano tem em média 3600 furadas no dedo. Situação que traz para além do desconforto, dores e perda de sensibilidade dos dedos pela necessidade de suas frequências.
6. O Autor apresenta descontrole glicêmico com vários episódios de hipoglicemia em diversos horários do dia, ocasionando posteriormente uma hiperglicemia de rebote.

7. Além disso, a fase hormonal do adolescente e as dosagens diárias da Somatropina elevam por si a glicemia, o que dificulta manter o nível glicêmico esperado do autor.
8. A médica que acompanha o Autor, indicou em seu laudo médico, que em virtude das múltiplas doses de insulina (LANTUS/DEGLUDECA e HUMALOG/NOVORAPID) necessárias ao tratamento e da grande variabilidade glicêmica,foi prescrita e indicada a monitorização continua da glicose através do uso do aparelho FreeStyle Libre da About, Kit sensor com 2 (duas) unidades mensais e o leitor, único método terapêutico disponível ao paciente a fim de promover melhora no controle glicêmico e amenizar as complicações desta patologia, eis que o método tradicional já não é suficiente, seja por causa do sofrimento do paciente ou pela baixa adesão ao tratamento.
9. O diferencia do Libre aos demais sistema de leitura capilar é fornecer um quadro glicêmico completo ao mostrar o nível atual da glicose. Além disso, é possível saber na hora como seus níveis de glicose estão se alterando, ao posicionar o leitor sobre o sensor para fazer a leitura rápida obtém um quadro de glicose completo, incluindo o nível atual da glicose, um histórico de 8 horas e uma seta de tendência mostrando se o seu nível glicêmico está subindo, baixando ou permanecendo estável.
10. Para a sua surpresa, a solicitação feita pela parte Autora foi negada pela ré em dia 16 de Abril de 2021, indicando que o contrato ao qual o Autor é vinculado "não possui cobertura contratual para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Além disso, trata-se de procedimento que não consta no Rol da ANS..
11. A UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (UNIMED RECIFE), vem se negando a autorizar, quais sejam: (a) Kit Inicial de FreeStyle Libre que inclui: LEITOR + SENSOR. (b) SENSOR (2 sensores ao mês).
12. Com demonstrado, a prescrição do tratamento foi indicada através de laudo médico firmado por profissional médico que acompanha o Requerente há 05 (cinco) anos e que, por este motivo, possui melhores condições de prescrever o tratamento correto.

Pelo exposto requereu: (a) a Concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, para determinar que seja a empresa ré compelida a ARCAR COM as despesas inerentes ao tratamento do adolescente atraves do fornecimento do aparelho FreeStyle Libre da About, Kit sensor 2 (duas) unidades e o leitor dos sensores de monitoramento FreeStyle Libre e (b) em sede de cognição exauriente a confirmação da liminar e reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Despacho determinando que o demandante comprovasse o seu comprometimento econômico, trazendo aos autos comprovantes de rendimentos atualizados, bem como a última declaração do Imposto de Renda da genitora do autor, MARCIA REGINA MOURA DA SILVA MIRANDA, que permitam seu enquadramento como beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos da Lei (id. 80377734).
Pagamento das custas (petição de id. 81390018).

Indeferimento do pedido de tutela (decisão de id. 82260883).
A parte ré apresentou sua defesa (Id. nº 85681125) alegando em suma que:

1. Os aparelhos e insumos descritos na exordial e pelo o qual o autor pugna pelo fornecimento destinam-se a tratamento exclusivamente domiciliar e fora do ambiente hospitalar.
2. Não há dúvidas, portanto, de que a aparelhagem que lhe foi prescrita é de natureza domiciliar e não se relaciona ao tratamento de neoplasia e seus efeitos colaterais (exceção legal de obrigatoriedade para casos de medicamentos e insumos para uso domiciliar).
3. A Lei Federal n. 9.656/98 é bastante elucidativa nesse sentido, ao tratar das exceções às coberturas obrigatórias em seu art. 10, inc. VI, excluindo o fornecimento de medicamentos/insumos para tratamento domiciliar.
4. Além da exclusão legal (ausência de cobertura obrigatória) acima referida, o artigo 17 da Resolução Normativa n. 465/2017 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, trata expressamente da exclusão assistencial da cobertura requerida pela parte autora.

> Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano de referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
> (...)
> VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;
> VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

5. O Parecer Técnico n. 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, expedido pela ANS, também é bastante claro sobre a ausência do dever de cobertura de medicamento/insumos destinados a tratamento domiciliar.
6. Nesse sentido, a negativa praticada pela Unimed Recife não se revela um ato de insensibilidade. Na verdade, a cooperativa médica não pode ser obrigada a custear o fornecimento de insumos/aparelhos/medicamentos com clara e expressa exclusão contratual, legal e normativa.
7. Cabe destacar que os aparelhos e insumos requeridos pelo demandante se configuram como uma e não a única forma de tratamento e acompanhamento da patologia que o acomete.
8. Salienta-se que PARECER TÉCNICO Nº 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, expedido pela ANS, também é bastante claro sobre a ausência do dever de cobertura de materiais não ligados a ato cirúrgico.
9. Dessa forma, fica claro que não há obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos e equipamentos aparelho FreeStyle Libre da About, Kit sensor 2 (duas) unidades e o leitor dos sensores de monitoramento FreeStyle Libre de uso domiciliar requeridos pelo demandante.
10. Portanto, convém salientar que o contrato entabulado livremente entre as partes prevê cobertura de todos os procedimentos de cobertura obrigatória que constem no rol da ANS.
11. Além de todo o exposto, é importante frisar que no dia 10 de dezembro de 2019, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp. 1.733.013 (docs. 03), fixou o entendimento no sentido de que os planos de saúde não são obrigados a custearem procedimento que não esteja previsto no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde.
12. No presente caso, o fornecimento dos materiais e insumos requeridos foi recusado por não possuir cobertura contratual, tampouco legal, definida pelo rol da ANS.
13. Por fim, cabe ainda destacar que não restou comprovado no processo que o equipamento FreeStyle Libre é indispensável ao tratamento do autor e que o glicosímetro não poderia obter o mesmo efeito, ainda que por método mais desconfortável.
14. Dos fatos narrados pela parte autora não se vislumbra a configuração dos danos morais.

Sob esses fundamentos, requer que a demanda seja julgada improcedente.

Réplica à Contestação (id. 86380985).

Despacho de Provas (id. 88431944), sem qualquer pedido de dilação probatória.

ISSO POSTO, PASSO A DECIDIR:

1. DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO:

Faço constar em boa hora que a Constituição Federal prescreve em seu artigo 1º, inciso III que:

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
> (...)
> III - a dignidade da pessoa humana.

(...)

Especificamente em seu artigo 5º, a Carta Cidadã de 1988, ao tratar dos direitos e garantias individuais, reconhece a inviolabilidade do direito à vida.
Ora, o direito à vida é sem dúvida alguma o mais importante de todos os valores protegidos constitucionalmente, pois dele emana a eficácia de todos os demais, *v.g.*, saúde, moradia.
Desta feita, o Estado deve preservar a vida dos indivíduos, prestando todo o auxílio necessário para que, com esse direito assegurado, possa exercer todo o feixe de direitos fundamentais que dele emanam.
Ressalte-se, ainda, que o artigo 196 da CRFB/88, por sua vez, prescreve que:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A carta política, agora no artigo 199, prescreve ainda que:

> Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Verifica-se, pela leitura dos artigos supracitados, que a iniciativa privada pode promover à assistência à saúde; todavia, não obstante o serviço possa ser prestado pela iniciativa privada, ele deve ser prestado respeitando todas as normas constitucionais que versem sobre a garantia da saúde dos pacientes, evidentemente, daquele grupo fechado beneficiário do serviço, como no caso dos clientes das demandadas deste processo.
Dessa forma, deve às normas contratuais estipuladas entre o particular, prestador do serviço de saúde, e os contratantes serem regidas pelas normas, direitos e valores constitucionais supramencionados.

Feito esses esclarecimentos, destaco, ainda, que a relação objeto da presente lide é relação de consumo, regulada, por conseguinte, pelo Código de Defesa do Consumidor.
O referido Digestos Consumerista, no artigo 2º, estabelece que *Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final*.
Nessa definição se enquadra facilmente a requerente, pois aderiu ao seguro de saúde para assistência médica/hospitalar junto a segunda Ré, possuindo, portanto, natureza de consumidora *standard*, conforme estabelece a boa doutrina.
Doutra banda, inegavelmente, os requeridos são fornecedores de serviço posto no mercado de consumo, senão vejamos, o artigo 3º, *caput*, da Lei em tela:

> Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Ao meu ver, é desnecessária uma discussão mais aprofundada sobre a aplicação do CDC, pois é entendimento pacífico nos Tribunais que a relação em casos como o em tela é típica relação de consumo.
Nessa direção, sendo a relação uma relação de consumo, é logicamente aplicável a legislação consumerista ao caso concreto, conforme prescreve o verbete da súmula 469 do STJ (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde).
Entendo, portanto, sob esses fundamentos, que as normas consumeristas são aplicadas as caso em comento.

2. DO MÉRITO:

Faz-se necessário elucidar que o Digesto Processual Civil prescreve em seu artigo 36, que cabe (...) *ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.*
De mais a mais, prescreve ainda o artigo 341 que *Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas* (...).

Ora, analisando a contestação da ré, observo que a demandada alega promoveu a negativa de custeio/fornecimento do aparelho FreeStyle Libre, sob o argumento que essa negativa se deu de forma legítima, uma vez que não há previsão legal, normativa e contratual para a sua cobertura por se tratar de aparelhagem de natureza domiciliar sem previsão no ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS.
Em suma: a Ré afirma que a negativa é legítima, uma vez que é baseada em exclusão contratual que tem respaldo nas normas legais.

Dentro deste cenário, percebe-se que é incontroverso, face a não impugnação específica, que: (a) o demandante é segurado da demandada e foi diagnosticado com DIABETES MELLITUS do tipo 1 (CID-10: E.10), sendo essencial realizar várias vezes ao dia o autoexame através do aparelho glicosímetro, obtendo amostras de sangue capilar para testes sanguíneo (medição do nível de açúcar no sangue); (b) o menor faz uso de insulinas (LANTUS/DEGLUDECA e NOVORAPID/HUMALOG) de acordo com a contagem de carboidrato, sendo que para o referido método, necessita do acompanhamento diário da glicemia que o obriga a se submeter entre a 6 (seis) e oito (oito) glicemias capilares em apenas um dia; (c) foi prescrita e indicada a monitorização continua da glicose através do uso do aparelho FreeStyle Libre da About, Kit sensor com 2 (duas) unidades mensais e o leitor, único método terapêutico disponível ao paciente a fim de promover melhora no controle glicêmico e amenizar as complicações desta patologia; e que (c) a solicitação feita pela parte Autora foi negada pela ré em dia 16 de Abril de 2021, indicando que o contrato ao qual o Autor é vinculado "não possui cobertura contratual para fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Além disso, trata-se de procedimento que não consta no Rol da ANS.

Ou seja, na sua contestação a ré não nega a existência da doença nem a necessidade do procedimento e muito menos que a indicação do médico não é devida ao caso concreto, mas "apenas" sustenta que não tem obrigação de custear o referido aparelho porque não está no rol de coberturas da ANS e nem tem previsão contratual.

Nessa toada, esclareço de logo que a tese da defesa não pode prosperar, senão vejamos:

Faço de logo destacar que a Jurisprudência pátria é uníssona ao se posicionar pela abusividade da negativa do plano de saúde em não autorizar tratamentos prescritos pelos médicos responsáveis, uma vez que, sendo a especialidade coberta pelo plano em questão, cabe ao profissional habilitado promover o cuidado do paciente, requerendo os procedimentos necessários.
Desta feita, não cabe ao plano de saúde avaliar as prescrições médicas, fazendo juízo de valor do que deve ou não ser autorizado, ou seja: o contrato de seguro saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.
No caso em comento, deve ser observado os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, sendo vedado à seguradora perceber por anos a contribuição do segurado para se esquivar da cobertura da técnica requerida pelo médico para o doença coberta pelo plano, justamente quando do surgimento da doença e necessidade de tratamento.
O Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco se filia ao posicionamento aqui esposado reiteradamente quanto à abusividade da negativa de autorização de procedimentos solicitados pelo médico que se aplica também ao caso de negativa de determinada técnica para o

procedimento inequivocamente prescrita pelo médico, vejamos julgados recente a respeito do tema:

PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E MEDICAMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1- Procedimento solicitado por profissional médico como medida imprescindível ao tratamento da saúde do segurado. 2- Não pode ser negada cobertura a tratamento e medicamentos pelo simples fato de não constarem no guia da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, uma vez tenham sido prescritos pelo médico assistente e a enfermidade a ser tratada esteja prevista no contrato firmado entre as partes. 3- Cabível a indenização por danos morais em decorrência do agravamento do abalo psicológico em que se encontra o paciente, estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4- Montante fixado a título de danos extrapatrimoniais em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-PE - AGV: 3127691 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/09/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2013)

TJ-PE - Apelação APL 3701862 PE (TJ-PE) (http://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18393 apl-3701862-pe) Data de publicação: 27/04/2015 Ementa: Apelação Cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de exame de Tomografia de Coerência Ótica - OCT. Danos morais configurados. Manutenção do valor indenizatório. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime. I - Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas. II - A medicina em constante evolução, razão pela qual novas tecnologias relacionadas a exames e procedimentos médicos surgem a todo momento. Deste modo, não se pode falar em ausência de cobertura contratual de determinados exames que provavelmente nem existiam à época da contratação do plano de saúde em questão. IV - Nos contratos de plano de saúde devem incidir os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência e da vulnerabilidade não sendo legítimo à seguradora perceber por anos a contribuição do segurado para se esquivar da cobertura do tratamento indispensável à permanência da vida dele justamente quando do surgimento da doença. V - A conduta da operadora em negar custeio ao medicamento necessitado pela paciente frustrou a legítima expectativa de ser protegida no momento de infortúnio. Nessa ocasião, o dano é claro e presumido, considerando-se o abalo à moral da vítima, pois teve o estado de tensão psicológica e de angústia intensificados pelo tratamento recusado.VI - Valor indenizatório mantido em R$8.000,00, pois chega a ser inferior aos parâmetros adotados pelo STJ e por esta Corte em casos análogos.VII - Recurso não provido por unanimidade

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HEMODIÁLISE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE NÃO PODE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO. DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE EM CUSTEAR O TRATAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO APELO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.
(TJ-PE - AGV: 4156727 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2016)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA E MATERIAL INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. IMPLANTE DO SISTEMA ANGEL/MED GUARDIAN. APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS ENVOLVENDO OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE QUE ATUAM NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO É POSSÍVEL À OPERADORA LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. CABE AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE A ESCOLHA. DECISÃO TÉCNICA. PRECEDENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. MANTIDA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.

(TJ-PE - AGV: 3991422 PE, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 15/12/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CDC. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. NA ORIGEM: AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO "UTEROSCÓPICA DE DUPLO J". EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. CIRURGIA REQUERIDA SEGUNDO DIAGNÓSTICO DO PROFISSIONAL COMPETENTE. DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE EM CUSTEAR O TRATAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO APELO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.
(TJ-PE - AGV: 4034788 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 20/10/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2015)

De mais a mais, o fato do tratamento/técnica não está previsto no Rol de procedimentos obrigatórios da ANS não justifica a sua negativa quando o médico assistente atesta a sua necessidade, pois há muito tempo a jurisprudência já definiu que o rol supracitado nada mais é que um rol de coberturas mínimas, senão vejamos julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

Apelação Cível. Plano de saúde. Tratamento de radioterapia com técnica de modulação de intensidade no feixe. Negativa de cobertura. Abusividade. Incidência da legislação consumerista. Rol de procedimentos elencados pela ANS que serve apenas como referência para cobertura assistencial mínima. Dever de cobertura. Recurso não provido por unanimidade.
I **- Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.**
II - **Se o plano possui cobertura para a especialidade de oncologia e o tratamento mais eficiente a ser ministrado ao paciente nesse caso, segundo entendimento médico consiste radioterapia com técnica de modulação de intensidade no feixe não há razão para excluir o referido procedimento da cobertura securitária, sob pena de se negar ao beneficiário o tratamento adequado à sua enfermidade e, por consequência, ferir a própria finalidade do contrato firmado entre as partes.**
III - No caso, o médico assistente do segurado justificou a necessidade do tratamento em questão por ser a única opção terapêutica com finalidade curativa e ainda destacou a necessidade de urgência da autorização de cobertura devido à velocidade de aumento do tumor.
IV - O Rol da ANS não é taxativo, contendo apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória dos planos de saúde.
V - A previsão dos riscos segurados e as limitações de cobertura no contrato de seguro não consistem, por si só, em ilegalidade. No entanto, a possibilidade de predeterminar os riscos cobertos não justifica a estipulação de cláusulas abusivas e contrárias às disposições do CDC.VII - Recurso apelatório não provido por unanimidade.
(Processo APL 3850531 PE Orgão Julgador 3ª Câmara Cível Publicação 14/01/2016 Julgamento 17 de Dezembro de 2015 Relator Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto)

Quanto a este tema (taxatividade ou não do rol), destaco que nos últimos meses existiu uma séria insegurança jurídica, pois a divergência entre a 3ª e 4ª Turmas do STJ afetou tal tema para análise.
Antes de a Corte definir sobre a taxatividade ou não do rol foi publicada nova Lei reforçando a taxatividade do rol, situação que levou o STJ (2ª Seção) a definir pela taxatividade rol, entretanto com algumas exceções, chegando-se a conclusão que a tese adotada foi a da taxatividade mitigada.
Entretanto, em 21/09/2022, foi sancionada nova Lei de nº 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e trata dos planos privados de assistência à saúde.
Nesta nova Lei as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a financiar tratamentos que não estiverem na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Desta feita, a discussão sobre a natureza exemplificativa ou taxativa do rol fora sepultada com a nova Lei 14.454/2022 que previu expressamente que tal rol é um rol de cobertura mínima.
Por conseguinte prevendo a Lei a exemplificatividade do rol, não cabe a este Juízo acolher a defesa, de forma que se mostra ilegal a negativa de cobertura da técnica com base na ausência de sua previsão no rol, pois a Lei que trata dos planos de saúde, como já esclarecido nesta sentença, prevê claramente que o rol é exemplificativo.

Vê-se portanto, à luz da Lei e da jurisprudência supracitada, que o contrato do plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas, pois a indicação do tratamento e a forma do tratamento (técnica a ser utilizada) cabe ao médico do paciente, prevalecendo a sua indicação.

Destaco, ainda, que a tese da parte ré de que o tratamento é domiciliar e que por isso não tem obrigação de custeá-lo não pode prosperar, uma vez que a exclusão contratual só incide nos casos que o segurado escolhe fazer o tratamento em sua residência.
Ou seja: O plano pode negar a cobertura quando a escolha pelo tratamento domiciliar obedece a meros parâmetros de conveniência do paciente.

Entretanto, no caso concreto, a necessidade do uso do aparelho se revela indispensável para o tratamento, pois o médico no caso concreto indicoiu especificamente a sua utilização para o controle da diabetes graças às peculiaridades que existem no caso do demandante, não podendo o plano de saúde negar o custeio alegando que o seu uso em ambiente domiciliar excluiria a sua cobertura, pois a natureza contínua do tratamento exige que ele seja realizado fora do ambiente hospitalar ou ambulatorial.

Desta feita, em sendo caso que o tratamento domiciliar não tem relação com a mera conveniência do paciente não se mostra legítima a negativa de cobertura com base na cláusula contratual suscitada, até porque, como dito alhures, a sua utilização fora do ambiente hospitalar é medida necessária e integrada ao processo de controle da patologia.
Interpretar a norma como quer a demandada traria como consequência situações que os pacientes se veriam obrigados a permanecerem presos a leitos hospitalares para realizarem o tratamento da patologia.

Desta feita, a eventual alegação de que a negativa de cobertura é legítima porque o contrato não cobre a aparelhagem ou porque ele não consta no rol de coberturas obrigatórias da ANS não pode prosperar.

Por amor ao debate, os Tribunais pátrios já se manifestaram reiteradamente sobre o custeio por planos de saúde do aparelho FreeStyle Libre da About e de forma quase que uníssonas, salva raras vozes ao contrário, vão ao encontro do posicionamento adotado por este Juízo nesta sentença, senão vejamos alguns exemplos:

> APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Pleito de fornecimento de aparelhos FreeStyle Libre para uso contínuo, indicados ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 – Sentença de improcedência – Insurgência do beneficiário – Acolhimento – Prescrição médica – Doença com cobertura contratual – Abusividade da negativa reconhecida – Súmula nº 102 TJSP – Precedentes deste TJSP – Necessidade de fornecimento do equipamento e insumos pleiteados reconhecida – Demanda procedente – Tutela de urgência concedida – Sentença reformada – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
> (TJSP; Apelação Cível 1085962-33.2021.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022).

> Apelação Cível. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Beneficiário portador Diabete Mellitus. Indicação de uso do sistema Freestyle Libre que monitora e mede a glicose. Sentença de procedência que condenou a operadora de saúde a fornecer o dispositivo e a pagar R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. 1- Ao médico, profissional habilitado e responsável pelo tratamento, incumbe a escolha do melhor procedimento. Não cabe às operadoras de saúde prestar diagnósticos ou prognósticos. Comprovada a necessidade do tratamento perseguido pelo paciente, como condição para o seu restabelecimento, mostra-se abusiva a conduta da ré que inclusive desvirtua a natureza dos contratos, cujo objetivo principal é resguardar a incolumidade física dos beneficiários. 2- Teses defensivas de exclusão contratual e ausência de previsão no rol de procedimentos médicos obrigatórios da ANS que não se sustentam. Inexistência de exclusão contratual expressa. Rol da ANS que, de acordo com o STJ, é exemplificativo e representa a cobertura mínima a ser observada pela operadora de saúde. 3- Recusa que se mostra evidentemente ofensiva e, feita em momento dramático da vida do consumidor, configura prática inaceitável, merecedora de reparação por danos morais. 4- Desprovimento do recurso.
> (TJRJ; Apelação Cível nº: 0008573-91.2020.8.19.0205; Relator (a): Desembargador Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; Órgão Julgador: Décima Sexta Câmara Cível; Data do Julgamento: 28 de julho de 2021)

Posto isso, à luz desta fundamentação, outra solução não há que não seja julgar procedente o pedido autoral com a condenação da ré para que ela autorize e custeie INTEGRALMENTE o <u>fornecimento do aparelho FreeStyle Libre da About, Kit sensor 2 (duas) unidades e o leitor dos sensores de monitoramento FreeStyle Libre</u>, conforme prescrição médica.

A respeito do pleito de danos morais, constato que o requerente sustenta que a negativa de cobertura gerou danos morais indenizáveis.
É importante realçar que não se faz necessário analisar se houve falha na prestação do serviço, uma vez que neste manto sentencial já foi constatada a referida falha da demandada que não promoveu as autorizações e custeio do tratamento na forma indicada pelo médico quando deveria fazê-lo.

De logo, trago à baila o artigo 14 do CDC que trata da responsabilidade do fornecedor de serviços, aplicável ao caso concreto:

> Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O artigo 6º, VI, do mesmo diploma legal, por sua vez prescreve que:

> Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
> (...)
> VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Verifica-se, portanto, que a responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva, ou seja, a ilicitude da conduta, no sentido objetivo, aplicada ao caso concreto, com base nos artigos supra, depende de uma conduta contrária ao ordenamento que vai causar dano a outrem independente de culpa; faz-se necessário verificar, portanto, três requisitos: (a) Ação/omissão; (b) nexo de causalidade; (c) dano. Sendo esse o norte para a apreciação dos pedidos de danos morais.

Pelo que basta neste momento analisar se a falha na prestação do serviço gera dano moral a ser reparado e promover a definição *quantum* indenizatório.
Ou seja, faz-se necessário observar se os elementos da responsabilidade objetiva (ação/omissão, nexo causal e dano) são verificados no caso concreto.

O elemento (a) omissão está configurado, uma vez que a ré deixou de autorizar o tratamento/aparelho indicado pelo médico, impedindo o autor a se submeter ao tratamento indicado na forma prescrita, tudo isso de forma injustificada, pois era seu dever autorizar, o que pôs em risco a efetividade do tratamento do segurado.

O (b) nexo de causalidade também está demonstrado no caso concreto, pois em sendo reconhecido que a negativa de tratamento gera dano moral indenizável, este dano terá decorrido direta e imediatamente da negativa indevida de seu custeio pela ré.

Por fim, o (c) dano também se verifica no caso em comento, vez que o paciente está até hoje impedido de usar o aparelho graças ao comportamento da demandada.
Ora, não é razoável que se repute essa negativa como mero aborrecimento, pois a demandante se viu impedido de realizar o tratamento da forma prescrita pelo médico por resistência injusta da requerida em autorizá-la, o que gera *angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa quanto à sua recuperação*.
Os Tribunais Pátrios têm posicionamento sedimentado quanto a incidência de danos morais em casos análogos, como no caso de negativa de materiais:

> DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO DO AUTOR. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
> 1. Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de indenizar, pois a recusa injustificada de cobertura de procedimento essencial para o restabelecimento da saúde do paciente gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa quanto à sua recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.
> 2. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 3. Recurso conhecido e desprovido.
> (Processo: APC 20130110854890. Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA. Julgamento: 03/06/2015. Órgão Julgador: 5ª Turma Cível Publicação: Publicado no DJE : 16/06/2015 . Pág.: 233)

Quanto ao ao aparelho em questão, os tribunais também tem posição que a negativa de custeio gera dano moral:

> Apelação Cível. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Beneficiário portador Diabete Mellitus. Indicação de uso do sistema Freestyle Libre que monitora e mede a glicose. Sentença de procedência que condenou a operadora de saúde a fornecer o dispositivo e a pagar R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. 1- Ao médico, profissional habilitado e responsável pelo tratamento, incumbe a escolha do melhor procedimento. Não cabe às operadoras de saúde prestar diagnósticos ou prognósticos. Comprovada a necessidade do tratamento perseguido pelo paciente, como condição para o seu restabelecimento, mostra-se abusiva a conduta da ré que inclusive desvirtua a natureza dos contratos, cujo objetivo principal é resguardar a incolumidade física dos beneficiários. 2- Teses defensivas de exclusão contratual e ausência de previsão no rol de procedimentos médicos obrigatórios da ANS que não se sustentam. Inexistência de exclusão contratual expressa. Rol da ANS que, de acordo com o STJ, é exemplificativo e representa a cobertura mínima a ser observada pela operadora de saúde. 3- Recusa que se mostra evidentemente ofensiva e, feita em momento dramático da vida do consumidor, configura prática inaceitável, merecedora de reparação por danos morais. 4- Desprovimento do recurso.
> (TJRJ; Apelação Cível nº: 0008573-91.2020.8.19.0205; Relator (a): Desembargador Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; Órgão Julgador: Décima Sexta Câmara Cível; Data do Julgamento: 28 de julho de 2021).

De mais a mais, o caso em comento carece de "grande esforço dogmático" para a caracterização dos danos morais, uma vez que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssono ao estabelecer que esse tipo de negativa promovida por planos de saúde gera dano moral *in re ipsa*, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC)- DEMANDA POSTULANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO NA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO DA CONSUMIDORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL E ARBITRADA A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(Processo: AgRg no AREsp 144028 SP 2012/0002890-0. Relator(a): Ministro MARCO BUZZI. Julgamento: 03/04/2014. Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA. Publicação: DJe 14/04/2014).

***Ex positis*, na esteira destes entendimentos, levando em conta também o caráter pedagógico da indenização por danos morais, entendo como devido a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do demandante.**

DECISÃO:

Pelo exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial, e, por conseguinte:

a) Condeno a demandada a custear INTEGRALMENTE o tratamento do adolescente, ora demandante, através do fornecimento do aparelho FreeStyle Libre da About, Kit sensor 2 (duas) unidades e o leitor dos sensores de monitoramento FreeStyle Libre , conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

No mais, tendo em vista a certeza do direito e o perigo da demora, concedo o pedido de tutela provisória de urgência antecipada e determinando que a demandada, no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta sentença via Oficial de Justiça, custeie INTEGRALMENTE o tratamento do adolescente, ora demandante, através do fornecimento do aparelho FreeStyle Libre da About, Kit sensor 2 (duas) unidades e o leitor dos sensores de monitoramento FreeStyle Libre , conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

b) Condeno, ainda, a demandada a reparar a demandante - a título de danos morais - no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos monetariamente (Tabela ENCOGE) e acrescido de juros legais da data do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

c) Condeno, por fim, a demandada a restituir o autor no valor das custas processuais adiantadas para o ajuizamento do processo devidamente atualizadas (ENCOGE) e com juros legais de 1% a.m., ambos contados da data do recolhimento, bem como em eventuais custas finais complementares em favor do TJPE.

Pelo que **EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com base no artigo 487, inciso I, do C.P.C.

Arbitro os honorários a serem pagos pela demandada em favor dos advogados do demandante no importe de 15% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00).

Intimem-se as partes desta sentença.

Após o trânsito em julgado, determino que sejam tomadas as medidas legais para salvaguardar interesse público no recolhimento das eventuais custas finais complementares por parre da ré em favor do TJPE.

Cumpridas todas as determinações, arquive-se os autos.

P.R.I.

Recife, 1º de março de 2023.

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: LUZICLEIDE MARIA MUNIZ VASCONCELOS
15/03/2023 13:43:00
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 126874508

23031513430045400000123963505

IMPRIMIR GERAR PDF